



Roj: **SAP GR 329/2018 - ECLI:ES:APGR:2018:329**

Id Cendoj: **18087370042018100026**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Granada**

Sección: **4**

Fecha: **02/03/2018**

Nº de Recurso: **482/2017**

Nº de Resolución: **68/2018**

Procedimiento: **Civil**

Ponente: **ANTONIO GALLO ERENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA

SECCION CUARTA

ROLLO Nº 482/17

JUZGADO GRANADA Nº13

AUTOS J.ORDINARIO Nº 320/16

PONENTE SR.D.ANTONIO GALLO ERENA

SENTENCIA NUM. - 68

ILTMOS. SEÑORES:

PRESIDENTE

D. ANTONIO GALLO ERENA

MAGISTRADOS

D.MOISES LAZUEN ALCON

D.JUAN FRANCISCO RUIZ RICO RUIZ

En la ciudad de Granada dos de marzo de dos mil dieciocho. La Sección Cuarta de esta ltma. Audiencia Provincial, ha visto, en grado de apelación los precedentes autos de Juicio Ordinario, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Núm.13 de Granada, en virtud de demanda de "ESTUDIO GRANADA NORTE S.L.", representado por el Procurador D. Miguel Angel Moral Sánchez, y defendido por el Letrado D/ª Ana María Nestares Suárez, contra D. Evaristo representado por el Procurador D/ª Mercedes De Felipe Jiménez-Casquet y defendido por el Letrado D. Jorge Fernández Díaz.

Aceptando como relación los "Antecedentes de hecho" de la resolución apelada, y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La referida resolución fechada en cuatro de julio de dos mil diecisiete, contiene el siguiente Fallo: " Que estimando la demanda deducida a instancia de ESTUDIO GRANADA NORTE, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Ángel Moral Sánchez, contra D. Evaristo , representado por la Procuradora de los Tribunales Dª. Mercedes de Felipe Jiménez-Casquet, debo condenar y condeno al demandado al pago de 9.801,00€, más los intereses legales desde la presentación de la demanda y al pago de las costas causadas."

SEGUNDO.- Sustanciado y seguido el recurso de apelación interpuesto pro la parte demandada, se dio traslado a las demás partes para su oposición o impugnación; elevándose posteriormente las actuaciones a éste Tribunal señalándose día y hora para votación y Fallo.

TERCERO.- Han sido observadas las prescripciones legales de trámite. Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. ANTONIO GALLO ERENA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alega en fundamento del recurso la ineficacia de los contratos de gestión. Vulneración por la sentencia de los preceptos del Cc relativos al contrato de mediación o corretaje, Título I y II del Libro IV y las disposiciones relativas al mandato, Arts. 1709 y siguientes .

Con reiteración viene expresando el TS que los contratos celebrados por el factor de un establecimiento, empresa fabril o comercial, cuando notoriamente pertenezca a la misma, se entenderán hechos por cuenta de dicha empresa o sociedad, aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo de celebrarlos, o incluso se alegue abuso de confianza, transgresión de facultades o apropiación por el factor de los efectos objeto del contrato, siempre que estos contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró con orden de su comitente, o que éste aprobó su gestión en términos expresos o por hechos positivos. En este sentido dicho Tribunal en sentencias de 2 abr 2004 , STS 27 mar 2007 , STS 28 sep 2007 , se alude a dicha doctrina jurisprudencial dictada en interpretación y aplicación del art. 286 C.Com .

Como se dice en la sentencia de 31 may 2002 , el "factor notorio" había ejercido como colaborador y dependiente del empresario, ..., y por ello le alcanza la presunción legal de que los actos jurídicos en los que intervino han de entenderse hechos por cuenta y para la sociedad en la que estaba integrado, al tratarse de operaciones relativas o relacionadas con el giro o tráfico mercantil del establecimiento principal, que es donde opera la defensa de los terceros de buena fe,..., siendo intrascendente que no se hubiera expresado en la antefirma de las facturas la condición con la que dicho factor actuaba. Antes en la sentencia 18 nov 1996 , citada luego por otras, resume el significado del art. 286 C.Com . expresando: "A estos colaboradores dependientes del empresario y en relación laboral de subordinación, generalmente estable, les asiste la presunción legal..., de que los contratos que efectúan se entienden hechos por cuenta de la sociedad o entidad en la que están integrados, es decir, que los llevan a cabo en nombre de su principal, siempre que los negocios concertados se refieran al propio giro o tráfico de la empresa a la que pertenecen."

Pero es que, además, en este caso la sociedad mercantil por la que actuó el Sr. José y este mismo así lo ha puesto de manifiesto, de manera que nos encontramos ante un contrato plenamente valido que además el propio recurrente ya antes ha reconocido, documento nº 15 de la demanda, y que en cualquier caso la primera que reclama con sustento en el referido contrato, habría confirmado.

En consecuencia la eficacia del contrato en que se sustenta la demanda es clara, la representación con la que actuó el Sr. José resulta suficiente tal como se recoge en la resolución apelada con referencia a su propia declaración y la del legal representante de la actora así como la actuación de esta reclamando las obligaciones del contrato extrajudicialmente y con la interposición de la demanda, de manera que en forma alguna se vulnera las disposiciones que regulan el mandato, Arts. 1709 y ss del Cc ni las del contrato de mediación o corretaje.

SEGUNDO.- Seguidamente se alega abusividad de la cláusula 12 del contrato en relación a lo previsto en el artículo 10 bis 1 de la Ley 26/1984 .

De entrada debemos resaltar que al cláusula a que se refiere el recurrente en este caso, nada tiene que vez con la que se trataba en la sentencia de esta Sección de 14 de marzo de 2005 , en el que era la compradora quien impugnaba lo que se incluía en el documento de visita al inmueble por persona que no había concertado el contrato de mediación o corretaje. Aquí por el contrario se trata del dueño del piso que encarga, el 19-8-2015, la gestión de venta del inmueble a la actora, con las condiciones y periodo indicado.

La discutida estipulación que prevee la obligación del vendedor del pago de los honorarios pactados en el supuesto de que sin justa causa se negara a aceptar una propuesta de compraventa conforme al encargo o que habiendo aceptado la propuesta se negase a firmar el contrato de compraventa, entendemos que es evidentemente clara y tiene sustento en la bilateralidad del contrato con reciprocidad de obligaciones, que no resultará incardinable en el referido precepto, no pudiendo considerase abusiva. Este pacto tiene como finalidad indemnizar a la entidad que ha cumplido todas sus obligaciones derivadas del contrato, los perjuicios que nacen única y exclusivamente del incumplimiento de quien encargo la gestión de venta del inmueble, encontrando causa en dicha injustificada conducta que ha frustrado la compraventa, todo lo que tiene sustento en lo dispuesto en los Arts. 1101 y siguientes en relación con el 1152 del Cc .

Pero es que además las obligaciones del mediador quedaron plenamente cumplidas. En este sentido el TS en sentencia de 21-5-2014 , expresa: " ...la delimitación o caracterización, ciertamente compleja, que encierra la atipicidad del contrato de mediación, debe tenerse en cuenta lo ya señalado por esta Sala en su sentencia,

de 8 de marzo de 2013 (núm. 105/2013) (RJ 2013, 5523) , a propósito del derecho de mediador a recibir la correspondiente retribución tras la realización de las gestiones o del encargo encomendado: (Fundamento de Derecho Segundo, números tercero y cuarto) "3. A juicio de esta Sala, la decantación conceptual que cabe establecer a estos efectos de la caracterización de la figura se sustenta en dos ejes interpretativos, principalmente.

El primero viene referido al carácter de contrato principal que tiene el contrato de mediación, esto es, con sustantividad propia, de forma que, aunque tenga como posible finalidad el facilitar la celebración de otro ulterior contrato, no cabe establecer un vínculo causal directo entre ellos teniendo, por lo tanto, autonomía en su respectiva eficacia jurídica. La precisión resulta útil a la cuestión doctrinal apuntada en la medida en que el alcance de la gestión del mediador, particularizado en la dialéctica entre la perfección o ejecución del contrato, no debe resolverse de un modo inverso, esto es, desde el contexto finalístico o desarrollo negocial del contrato proyectado, sino que debe estar informado en el seno del contrato de mediación como contrato principal y sustantivo. En este sentido, que el contrato no se haya ejecutado, por sí solo, no resulta determinante del proceso interpretativo.

El segundo eje, con mayor incidencia si cabe, viene referido a la naturaleza de contrato atípico que caracteriza el contrato de mediación. Desde esta perspectiva puede afirmarse que tanto desde el desenvolvimiento técnico de la figura; su separación de la comisión mercantil, su consideración de contrato innominado "facio ut des" o su derivación del contrato de mandato, como desde el plano de la integración o ajuste de su tipicidad, ya mediante la yuxtaposición de varios contratos típicos o de obligaciones o pactos pertenecientes a distintos tipos contractuales, la atipicidad del contrato de obra que caracteriza a las obligaciones de resultado no ha formado parte de estos procesos de caracterización de la figura, por lo que difícilmente puede deducirse, salvo pacto expreso de las partes o aplicación de los usos y costumbres, que de la caracterización básica de la figura la obligación del mediador pueda calificarse de una propia obligación de resultado que determine su perfección con la ejecución o consumación de una situación jurídica que posibilitada por el mediador, no obstante, no depende ya de su marco de actividad. Conclusión que afecta a la propia estructura del contrato, pues si bien la perfección del encargo actúa como condición del derecho de retribución (onerosidad), sin embargo, no crea ningún deber jurídico o prestacional propiamente dicho que opere un fenómeno de reciprocidad obligacional, más allá de la mera bilateralidad del contrato.

4. Desde esta perspectiva, esto es, desde la caracterización general del contrato como medio interpretativo del alcance de la gestión encomendada se comprende mejor que las referencias usuales a la "perfección del encargo" y, en su caso, al "éxito de la mediación" resultan aplicables aquellos supuestos en donde la actividad del mediador determina la existencia del marco o vinculación negocial que posibilita la finalidad adquisitiva querida por el oferente, con independencia de la propia ejecución o consumación del mismo; de forma que en el supuesto de opción de compra debe entenderse que ya se produce este marco de vinculación negocial en favor del oferente que le permite la finalidad adquisitiva (perfección del encargo), con independencia de que dicha opción resulte o no ejercitada por el comitente. Todo ello, como se ha señalado desde el principio, salvo que la autonomía de las partes o la aplicación al caso de los usos y costumbres concreten un determinado resultado adquisitivo o entramado negocial.

La conclusión alcanzada, por tanto, resulta igualmente aplicable a todos aquellos supuestos en donde conseguida la perfección o eficacia del marco negocia! el cumplimiento o consumación del mismo no se da por causas ajenas a la gestión encomendada, supuestos de desistimiento o incumplimiento contractual del oferente, pero también del propio y natural desenvolvimiento de la relación contractual, casos de la eficacia modalizada bajo condición resolutoria o suspensiva".

En razón a todo ello esta Audiencia en sentencia de 3-6-2016 de la Sección Tercera , considera procedente el derecho al cobro del mediador por la reciente jurisprudencia que entiende ha lugar cuando conseguida la finalidad del encargo, el contrato de compraventa, finalmente, no llega a celebrarse por desistimiento o incumplimiento del oferente.

TERCERO.- Finalmente se alega error en la valoración de la prueba respecto de lo que debemos resaltar que si bien en nuestro sistema procesal la segunda instancia se configura como una -revisio prioris instantiae-, en la que el Tribunal Superior u órgano -ad quem- tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de la primera, tanto en lo que afecta a los hechos (-quaestio facti-) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (-quaestio iuris-), no obstante ello la revisión de los hechos y valoración probatoria debe sustentarse en la realidad de la concurrencia de error que resulte patente.

En este sentido es criterio de esta Sala que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación sea fundamentalmente la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de primer grado sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la

apreciación probatoria realizada por quien ha presidido el acto del juicio, en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad, y aun cuando actualmente la grabación de la vista posibilita al Tribunal de apelación visionar perfectamente todo ello, debe añadirse la consideración de que el uso que haya hecho Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso se motive o razone adecuadamente la sentencia (STC 17-12-85 , 23-6-86 , 13-5-87 , 2-7-90 , 4-12-92 y 30-10-94 , entre otras) únicamente deba ser rectificado, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo", que haga necesaria, por criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Por ello, dado que los preceptos relativos a las pruebas practicadas no contienen reglas valorativas sino admoniciones a los Jueces y una apelación a la sana crítica y al buen sentido, para destruir una conclusión presuntiva del Juzgador, debe demostrarse que ha seguido, al establecer dicho nexo o relación, un camino erróneo, no razonable, contrario a las reglas de la sana lógica y buen criterio, constituyendo la determinación de dicho nexo lógico y directo un juicio de valor que está reservado a los Tribunales y que se ha de respetar en tanto no se acredite que es irrazonable.

Prescindir de todo lo anterior es pretender modificar el criterio del Juzgador por el interesado de la parte recurrente, debiendo añadirse que en modo alguno puede analizarse, o, mejor, impugnarse la valoración probatoria del Juzgador de Instancia, mediante el análisis de cualquier prueba de forma individualizada y parcial, sin hacer mención a una valoración conjunta.

CUARTO.- En el supuesto de autos en lo que afecta el error denunciado, no se concreta norma legal que pueda haberse infringido o directriz de la lógica o la razón que se pudiese haber conculcado, en relación a cuanto se concluye sobre la documental y la testifical, tanto del Sr. José como del Sr. Carlos Daniel a que se refiere la parte, sin que el hecho de que el Sr. Carlos Daniel , sea transportistas imposibilite que no pueda ser cierto cuanto declaró. Se completa ello con la documental y con la declaración del representante de la actora y del Sr. José , todo lo que aparece razonablemente argumentado en la resolución apelada de manera que no se evidencia error.

QUINTO.- Derivado de todo lo expuesto, este Tribunal aceptando el criterio del Juzgador "a quo" y considerando razonables, en general, en su conjunto las conclusiones que se contienen en la sentencia impugnada que en forma alguna resultan desvirtuadas con las alegaciones del escrito de recurso, con remisión a aquellas a efecto de obviar inútiles reiteraciones, deberá desestimar el mismo.

SEXTO.- Desestimándose el recurso sin que concurran en el supuesto de autos serias dudas de hecho o de derecho, la parte apelante deberá ser condenada al pago de las costas de esta alzada, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 394 y 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, este Tribunal dispone el siguiente,

FALLO

Que desestimándose el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de la que dimana este Rollo, debemos confirmar y confirmamos íntegramente la misma, condenándose a la parte apelante al pago de las costas del recurso con pérdida del depósito al que debe darse destino legal.

Contra la presente resolución cabe recurso de Casación, por interés casacional, y, en su caso, recurso extraordinario de infracción procesal, que deberá interponer ante este Tribunal dentro del plazo de veinte días contados desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.